HABEAS CORPUS 278.451 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: OCTAVIO HUMMEL MENDONCA NETO
IMPTE.(S)	: MARIA EDUARDA BARBOSA
COATOR(A/S)(ES)	: PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de *habeas corpus* impetrado por Maria Eduarda Barbosa, em favor de Octavio Hummel Mendonça Neto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 121.477/SP.

Colho da decisão impugnada (eDOC 6):

> "Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OCTAVIO HUMMEL MENDONCA NETO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:
>
> > EMENTA: Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Entorpecentes. Pedido revisional indeferido. I. Caso em Exame 1. Revisão criminal proposta por Octavio Hummel Mendonça Neto, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, buscando aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e substituição da pena por medidas alternativas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável o redutor do tráfico privilegiado ao peticionário, considerando sua dedicação a atividades criminosas e a quantidade de drogas apreendida. III. Razões de Decidir 3. A fundamentação adotada para descartar o redutor do tráfico privilegiado está baseada na dedicação habitual do peticionário ao narcotráfico, evidenciada por elementos concretos dos autos. 4. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria sem erro judiciário ou contrariedade à prova dos autos. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C0B1-61E4-A349-B3BE e senha 5977-11BC-B023-BA54

sem erro judiciário.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a negativa da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, teria sido mantida sem suporte fático-jurídico idôneo, a despeito da primariedade e dos bons antecedentes do paciente.

Alega que não há prova concreta de dedicação habitual do paciente às atividades criminosas, tampouco vínculo com organização criminosa, de modo que estariam preenchidos os requisitos positivos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Argumenta que a quantidade e a variedade de entorpecentes já foram valoradas na primeira fase para exasperação da pena-base, sendo indevida sua reapreciação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

Defende que mensagens extraídas do aparelho celular, descritas como tratativas sobre "produto não especificado", não demonstram, de forma segura, habitualidade delitiva, não sendo possível presumir que se tratava de drogas.

Expõe que, reconhecida a minorante, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos legais.

Requer, liminarmente, a colocação do paciente em regime aberto até o julgamento definitivo do presente writ. E, no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C0B1-61E4-A349-B3BE e senha 5977-11BC-B023-BA54

> mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos" (eDOC 6)

No STJ, o *habeas corpus* foi indeferido liminarmente.

Requer a impetrante, liminarmente, "*a imediata readequação provisória da situação prisional do paciente para regime compatível com a pena resultante da incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, sejam suspensos os efeitos do ato impugnado no ponto relativo ao regime mais gravoso*" (eDOC 1, p. 10). No mérito, pleiteia a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena e fixação de regime prisional compatível. Subsidiariamente, pede a cassação do ato impugnado, com determinação de nova análise da terceira fase da dosimetria da pena, ou a concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se, de início, que o presente *writ* trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.

Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.

É este, **em parte, o caso dos autos**.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C0B1-61E4-A349-B3BE e senha 5977-11BC-B023-BA54

sentença condenatória (eDOC 5, p. 133-134):

> Ademais, os dados extraídos do aparelho telefônicos apreendido com o réu demonstram a venda de entorpecentes, como apontado pelo Ministério Público em Memoriais. Existe conversa com terceiro de codinome "Fuba" revelando a venda de entorpecentes, inclusive com negociação de preço e envio do comprovante de pagamento. A mensagem do terceiro descortina, ademais, atividade reiterada de venda, pois existente quase 1 semana antes da prisão e com o trecho "Hj tem como 8 por 70 já faço o pix", deixando claras tratativas anteriores, o que também afasta a aplicação do privilégio:
>
> [...]
>
> Inaplicável o tráfico privilegiado ao referido réu, considerando que, apesar de primário, as circunstâncias concretas do caso demonstram sua dedicação a atividades delituosas, o que pode ser extraído das mensagens obtidas através do seu aparelho telefônico, como exposto na fundamentação, circunstância que indica a desenvoltura regular de atos relacionados ao tráfico, além de tornar mais grave e reprovável o delito.

E, ainda, do acórdão proferido pelo TJSP no julgamento da apelação interposta pela defesa (eDOC 3, p. 24-25):

> E não era o caso de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, como se sabe, a *mens legis* ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, uma vez que o apelante foi surpreendido com quantidade significativa de drogas, dentre elas o crack, de alto poder vulnerante, parte das drogas que portava e outra parte de guardava no interior de sua residência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C0B1-61E4-A349-B3BE e senha 5977-11BC-B023-BA54

> O apelante possuía dinheiro, mais de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), além disso, conforme relatório de extração de dados do aparelho de telefone celular apreendido, conforme bem destacou o Ministério Público nas alegações finais (fl. 282), constata-se que o apelante trava conversas com interlocutores admitindo a posse de maconha e organizando a venda de produto não especificado, tudo a evidenciar sua predisposição e engajamento para o narcotráfico e que não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o seu envolvimento habitual com a atividade criminosa.

Sabe-se que, para a concessão do redutor o réu deve cumprir **quatro requisitos**, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

Na sentença e no julgamento do apelo defensivo, assim como no julgamento da revisão criminal, as instâncias de origem afastaram a benesse, ao concluir que o réu se dedicava a atividades criminosas.

Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família.

Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos concretos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.

Conforme assentado na doutrina: "*A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena*" (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C0B1-61E4-A349-B3BE e senha 5977-11BC-B023-BA54

Na espécie, as instâncias de origem inferiram a habitualidade delitiva do paciente a partir da quantidade de entorpecentes apreendidos, da quantidade de dinheiro em seu poder e do teor de mensagens extraídas de seu aparelho celular, que, segundo consignado, demonstrariam a posse de drogas e fariam referência a "***venda de produto não especificado***" (eDOC 3, p. 25).

Ocorre que a pressuposição de que o "produto não especificado" corresponderia a substâncias entorpecentes não encontra amparo em elemento concreto dos autos, não passando de mera presunção.

Tal ilação, desacompanhada de comprovação idônea, não constitui fundamentação apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.

Ainda, tais circunstâncias, embora aptas a caracterizar o dolo de tráfico e distingui-lo do objetivo de consumo pessoal, não bastam, por si sós, para comprovar a dedicação à atividade ilícita ou que o agente praticasse reiteradamente a conduta proibida.

Deve o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a demonstrar a anterioridade da prática.

Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:

> "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C0B1-61E4-A349-B3BE e senha 5977-11BC-B023-BA54

> fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido" (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022).

> "Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)

Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C0B1-61E4-A349-B3BE e senha 5977-11BC-B023-BA54

diminuição de pena, **não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa**, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, confiram-se o HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022, e o HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019.

Assim, tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, **entendo que o paciente possui o direito à redução, uma vez que não há qualquer indicação inequívoca de envolvimento com organização criminosa e efetiva comprovação de dedicação à atividade criminosa**.

Ante o exposto, **nego seguimento** ao *habeas corpus* (RISTF, art. 21, § 1º), mas **concedo parcialmente a ordem de ofício** (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo de origem aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser definida motivadamente.

Comunique-se imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C0B1-61E4-A349-B3BE e senha 5977-11BC-B023-BA54